

1020424-87.2022.8.26.0224

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Repetição do Indébito

Magistrado: MARINA DUBOIS FAVA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 20/12/2022

... COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Furto de celular de correntista -

Transações bancárias não reconhecidas pelo demandante - Sentença de parcial procedência - Insurgência da parte ré - Responsabilidade da instituição financeira em garantir a segurança nos sistemas informatizados disponibilizados aos correntistas - Transações indevidas na conta corrente da parte autora após ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Cível

R. dos Crisântemos nº 29, 14º andar, Guarulhos - SP - cep 07091-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1020424-87.2022.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1020424-87.2022.8.26.0224

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Repetição do Indébito

Requerente:

Pedro Francisco da Silva

Requerido:

Banco Mercantil do Brasil S.A.

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARINA DUBOIS FAVA

Vistos.

Trata-se de ação proposta por Pedro Francisco da Silva em face de Banco Mercantil do Brasil S.A., sustentando, em síntese, que em 18/04/2022, foi surpreendido com ligação supostamente de preposto da Parte Ré informando sobre a tentativa de empréstimo em sua conta bancária, e que deveria realizar uma transferência pelo aplicativo, via "pix", para verificação e realização de carta de negatividade. Após a Parte Autora realizar aludida operação, transferindo para sua filha a quantia de R\$ 1,00, consultou novamente o aplicativo da instituição financeira Ré e notou a realização de empréstimos que totalizaram R\$ 9.774,00, com o desconto de duas parcelas, nos valores de R\$ 899,83 e R\$ 885,59, cada, além de outra transferência, via "pix", no valor de R\$ 8.030,00, em benefício de Jefferson Lucas Florencio, todas na mesma data. Informa ter comparecido à agência da Parte Ré para solucionar o problema, mas nada foi resolvido. Assim, pleiteia a declaração de inexigibilidade dos contratos de empréstimos nº 910001325410, 805074925, 805074921, 804440182 e 804763852, bem como a condenação do Banco Requerido à restituição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. Requereu a concessão da justiça gratuita e de tutela de urgência para cessação da cobrança das parcelas (fls. 01/25). Juntou documentos (fls. 26/58).

Ordenada emenda à inicial (fls. 59/60), atendida às fls. 63/65, com juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência (fls. 66/125). Concedida a justiça gratuita e indeferida a tutela provisória de urgência (fls. 126/129).

Devidamente citada (fl. 135), a Parte Ré apresentou contestação, suscitando, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, aduziu que os empréstimos teriam sido realizados por terceiro, e que não haveria responsabilidade da casa bancária pela fraude de que foi vítima a Parte Autora, que teria informado sua senha a terceiros. Em razão disso, assevera inexistir dever de indenizar. Subsidiariamente, pugnou pelo valor da indenização com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Também impugnou o pedido de repetição do indébito, por se tratar de golpe sofrido por culpa exclusiva do correntista. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos (fls. 143/150). Juntou documentos (fls. 151/199).

A Parte Requerida juntou novos documentos (fls. 203/243).

Houve réplica (fls. 244/248).

Determinada a especificação de provas (fl. 249), as partes informaram não ter interesse na produção de outras provas além das existentes nos autos (fls. 252/253 e 254/255).

É o relatório. Fundamento e decido.

Passo à análise da preliminar.

Não há que se falar em ilegitimidade da Instituição Financeira Ré, porquanto a Parte Autora com ela mantém contrato de prestação de serviços bancários, com manutenção de conta corrente, sendo a Casa Bancária Requerida a mantenedora das transações bancárias e guarda dos valores pertencentes ao consumidor. Demais disso, foi quem pactuou com a Parte Autora os valores dos empréstimos contratados e efetuou os depósitos em conta, exsurgindo disso sua legitimação passiva.

Não havendo outras preliminares a dirimir e estando presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, passo ao julgamento da demanda no estado em que se encontra, na forma do art. 355, inciso I, do CPC, eis que a prova constante dos autos é suficiente para a justa solução da lide.

No mérito, os pedidos são procedentes.

De início, importa registrar que se aplica a legislação consumerista ao presente caso: a Parte Autora se encaixa na acepção de consumidor trazida pelo artigo 2º do CDC, bem como denota manifesta hipossuficiência técnica e documental quando comparada à Ré, que possui a vasta maioria dos meios e documentos necessários ao regular deslinde do feito e posterior julgamento.

No caso, cuida-se de ação em que a Parte Autora teve disponibilizados valores em sua conta bancária decorrentes de empréstimos supostamente não contratados junto à Parte Ré, bem como transferência de valores via "pix" por ela não realizada. O Banco Requerido, por sua vez, alega que houve fraude perpetrada por terceiro estranho aos autos e que decorreu de culpa exclusiva da vítima, ora Parte Autora, que teria fornecido a senha de acesso.

Assim, denoto que a questão controvertida cinge-se à verificação da presença da excludente de responsabilidade da culpa exclusiva da vítima, levantada pela Parte Ré.

Com efeito, descabe no caso concreto a imposição à Parte Autora do ônus de provar o não fornecimento das senhas a terceiro. Em se tratando de prova negativa, é cediço que sua produção é extremamente difícil, beirando a impossibilidade, tal por que chamada de prova diabólica.

De outro lado, a alegação da Parte Ré de que o consumidor forneceu as senhas a terceiros decorre do fato de a Parte Autora possivelmente ter sido vítima de estelionatários que, após contatar o correntista, o orientaram a realizar transferência via "pix" a alguém da família, ocasião em que, possivelmente, clonaram a senha e suas informações, que, por sua vez, possibilitaram o acesso ao aplicativo e, em seguida, a contratação de empréstimos bancários e a realização de

transferências via "pix".

Neste ponto, não vislumbro culpa em sentido estrito da Parte Autora na sujeição ao golpe, pois não se cuida de fraude grosseira, apresentando potencial para enganar até o homem médio.

Assim, concluo não ter havido culpa exclusiva da vítima no caso concreto, mas responsabilidade objetiva da Parte Ré, porquanto o ocorrido claramente derivou de falha na segurança do serviço prestado pela instituição financeira, cujo dano, produto da falha, caracteriza fortuito interno que, pela aplicação da teoria do risco-proveito, deve ser suportado pela fornecedora, forte na máxima de que aquele que se apropria dos lucros advindos do exercício da atividade deve também arcar com os prejuízos dele decorrentes.

Assim, uma vez estabelecida a premissa de que a Parte Autora foi vítima de golpe, mister considerar que os empréstimos realizados – todos na mesma data, diga-se – são ilegítimos, até por que, além de refugirem do perfil do correntista, na sequência, houve a transferência para a conta do golpista, devendo ser declarados inexigíveis.

A repetição do indébito também é devida, pelo dobro do valor, mas deverá abarcar tão somente as parcelas dos empréstimos debitados indevidamente de sua conta bancária e/ou benefício previdenciário, considerando que o valor do "pix" espúrio teve por objeto os valores depositados pela própria Parte Ré, que é quem suportou o prejuízo.

Por fim, também vislumbro lesão extrapatrimonial sofrida pela Parte Autora.

Com efeito, evidente que a situação narrada não é de mero aborrecimento ou dissabor, decorrendo o dano moral da inegável sensação de insegurança que sobrevém a quem tem transações efetuadas em sua conta corrente e se vê compelido a efetuar o pagamento de despesas não reconhecidas, assim também por ter sua conta bancária invadida por fraudadores em razão de falha dos sistemas de segurança do aplicativo da Casa Bancária Ré.

Quanto ao valor a ser indenizado, é cediço que o montante indenizatório deve ser suficiente para reparar o dano causado e, ao mesmo tempo, não pode servir de fonte de enriquecimento desmedido.

A quantia deve ser apta a satisfazer a dor da vítima e a dissuadir, de igual e novo atentado, a Parte Autora da ofensa, considerando-se, no mais, a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo ofendido, a capacidade do causador do dano e, finalmente, as condições sociais das partes.

Forte em tais fatores, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afigura-se justa e adequada a indenização no valor de R\$ 5.000,00, quantia que se mostra razoável e suficiente para satisfazer os danos sofridos pelo consumidor, alcançar a função satisfatória da indenização por danos morais e incorporar, a um só tempo, o caráter punitivo e compensatório, sem configurar fonte de enriquecimento sem causa.

Em arremate, confira-se o entendimento do E. Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, SOB O ARGUMENTO DE REALIZAÇÃO FRAUDULENTA DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS, VIA PIX, BEM COMO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, POIS A CAUSA EM DISCUSSÃO VERSA SOBRE QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DE FRAUDE. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS, NO MESMO DIA, EM VALORES ELEVADOS, QUE DESTOARAM DO PERFIL DE MOVIMENTAÇÕES DO CORRENTISTA. REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DE METADE DO VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMO IMPUGNADOS, BEM COMO PARA CONDENAR O RÉU, À RESTITUIÇÃO DE METADE DO VALOR CONTESTADO. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NOS TERMOS DO ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL, UMA VEZ QUE A CONDUTA DE AMBAS AS PARTES CONTRIBUIU PARA A CONCRETIZAÇÃO DO EVENTO DANOSO. POSSIBILIDADE DE CONSIDERAR A CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR PARA MITIGAR A RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO AUTOR E DO BANCO, TENDO EM VISTA QUE O AUTOR INFORMOU DADOS PESSOAIS A TERCEIROS, E O SEGUNDO AUTORIZOU OPERAÇÕES FINANCEIRAS COM CARACTERÍSTICAS E

VALORES QUE DESTOAVAM SIGNIFICATIVAMENTE DO PADRÃO DE CONSUMO DE SEU CLIENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Apelação Cível 1013264-11.2021.8.26.0009; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/12/2022; Data de Registro: 12/12/2022) (grifei);

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Transações bancárias não reconhecidas pelo demandante - Aplicativo bancário - Perda do aparelho - Sentença de parcial procedência - Insurgência da parte ré - Responsabilidade da instituição financeira em garantir a segurança nos sistemas informatizados disponibilizados aos correntistas - Transações indevidas na conta corrente da parte autora após perda de aparelho celular - Responsabilidade objetiva do prestador de serviço - Inteligência do artigo 14 da legislação consumerista - Verossimilhança das alegações demonstrada - Operações que destoam do perfil de consumo do correntista - Falha na prestação dos serviços evidenciada - Responsabilidade civil objetiva do réu não afastada - Aplicação da Súmula nº 479 do STJ - Precedentes desse E. Tribunal de Justiça - Necessidade de ressarcimento das quantias indevidamente transferidas - Inovação recursal - Réu que deixa de impugnar, no momento oportuno, de forma pormenorizada, as alegações da parte autora, só o fazendo nessa esfera recursal - Inadmissibilidade, sob pena de violação ao contraditório e duplo grau de jurisdição - Sentença de parcial procedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP; Apelação Cível 1024667-25.2020.8.26.0554; Relator (a): Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/03/2022; Data de Registro: 21/03/2022, g.n.); (grifei);

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Furto de celular de correntista - Transações bancárias não reconhecidas pelo demandante - Sentença de parcial procedência - Insurgência da parte ré - Responsabilidade da instituição financeira em garantir a segurança nos sistemas informatizados disponibilizados aos correntistas - Transações indevidas na conta corrente da parte autora após furto de aparelho celular - Responsabilidade objetiva do prestador de serviço - Inteligência do artigo 14 da legislação consumerista - Verossimilhança das alegações demonstrada - Operações que destoam do perfil de consumo do correntista - Falha na prestação dos serviços evidenciada - Responsabilidade civil objetiva do réu não afastada - Aplicação da Súmula nº 479 do STJ - Precedentes desse E. Tribunal de Justiça - Necessidade de ressarcimento das quantias indevidamente transferidas - Danos morais configurados - Indenização - Redução - Cabimento - Quantum indenizatório reduzido para R\$5.000,00 (cinco mil reais) que melhor se amolda à hipótese, mostrando-se razoável e proporcional ao grau e tipo de ofensa perpetrada, bem como à extensão dos danos causados - Sentença de parcial procedência reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJSP; Apelação Cível 1060064-18.2021.8.26.0100; Relator (a): Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2021; Data de Registro: 15/12/2021, g.n.) (grifei).

Destarte, com amparo nos argumentos acima, a procedência dos pedidos é medida de rigor.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, para declarar inexistentes os contratos nº 910001325410, 805074925, 805074921, 804440182 e 804763852, bem como inexigíveis as parcelas deles decorrentes. Ainda, condeno a Parte Requerida à restituição das quantias indevidamente descontadas da Parte Autora, a título de parcelas pelos empréstimos, pelo dobro do valor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O valor decorrente da repetição do indébito deverá ser acrescido de juros de mora de um por cento ao mês e atualização monetária pela Tabela Prática do TJSP desde as datas em que efetivamente debitadas da conta bancária da Parte Autora. Já o valor dos danos morais deverá ser atualizado monetariamente pela Tabela Prática do TJSP, a partir do arbitramento, e acrescidos de juros de mora de um por cento ao mês, a

partir do evento danoso.

Em razão da sucumbência, arcará a Parte Requerida com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Por fim, de modo a evitar o ajuizamento de embargos de declaração, registre-se que ficam preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e cautelas de estilo.

Sentença registrada eletronicamente.

Publique-se. Intime-se.

Guarulhos, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA